

1501062-83.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... e trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 14 porções de maconha, 13 porções de cocaína e 9 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o réu trazia consigo na mencionada via pública – que é notória por ser ponto de narcotráfico – e tinha em depósito, no interior de uma lixeira, as drogas acima indicadas, para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501062-83.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501062-83.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO DOUGLAS SILVA DOMICIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

CAIO DOUGLAS SILVA DOMICIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 12h30min, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, na Rua Maracanã, 418, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Atibaia, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 14 porções de maconha, 13 porções de cocaína e 9 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o réu trazia consigo na mencionada via pública – que é notória por ser ponto de narcotráfico – e tinha em depósito, no interior de uma lixeira, as drogas acima indicadas, para o fim de comercializá-las.

Assim, no instante e que acondicionava parte dos entorpecentes no fundo da lixeira,

foi avistado por guardas municipais que passavam pelo local e, ao perceber a presença deles, tentou se afastar, bem como jogou algo de cor branca que tinha na mão, para trás de um muro de uma residência.

Tal atitude chamou a atenção dos agentes da lei que, ante a fundada suspeita, decidiram abordá-lo. Com efeito, em busca pessoal, encontraram consigo a quantia de R\$ 200,00, em notas trocadas, cuja origem ele não soube informar. Ato contínuo, os guardas acharam atrás do referido muro, no chão, sete porções de cocaína. Ademais, dentro da mencionada lixeira, encontraram o resto das drogas, todas separadas individualmente e prontas para a venda, além de verificarem que as demais porções de cocaína (que estavam dentro da lixeira) eram idênticas àquelas que foram arremessadas para trás do muro pelo réu.

Indagado sobre fatos, CAIO inicialmente negou a traficância, porém, ao ser conduzido até a delegacia, acabou por confessar o comércio ilícito de drogas. É certo, ainda, que o réu é conhecido no meio policial, pois, enquanto menor, respondeu a três procedimentos de apuração de atos infracionais equiparados a tráfico de drogas. E, para piorar, quando a equipe de guardas se preparava para levar CAIO ao distrito policial, apareceu um indivíduo conhecido pela alcunha de Ney Caroço, que é notório por seu envolvimento com o tráfico local, e questionou os agentes, em tom intimidador, sobre a necessidade de prender o réu.

Já na delegacia, CAIO negou a traficância.

Em laudo de constatação preliminar e em laudo químico-toxicológico, verificou-se que as substâncias apreendidas são entorpecentes constantes da lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

É certo que o crime em análise foi praticado na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20.

O flagrante foi convertido em preventiva às fls. 57/62.

O réu foi notificado (fls. 143), e apresentou defesa prévia (fls. 144/149), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 156/159).

O réu foi citado (fls. 185).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 200/201).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 202/208).

A defesa do réu requereu a procedência parcial da ação, postulando o afastamento da agravante do art. 61, II, j, do CP, alegando que não restou comprovado o melhor proveito à prática criminosa em razão do estado de calamidade. Pugnou pela aplicação da atenuante relativa à confissão, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação do regime aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade (fls. 212/213).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 11/14), no auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17/18), nas fotografias (fls. 33/35), nos laudos toxicológicos (fls. 108/110 e fls. 135/138), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, negou o crime. Disse que foi detido próximo a uma ponte e não estava anteriormente na praça do Jardim Imperial; ao ser detido e revistado, foi localizada a quantia de R\$ 200,00 em dinheiro, que pertencia à sua mulher, e um invólucro de maconha (um baseado); as drogas que foram apreendidas pertenciam a uns "moleques" que correram quando os guardas municipais chegaram; confirma que, na época em que era adolescente, respondeu por tráfico por três vezes (fls. 09).

Em juízo, interrogado, confessou os fatos. Disse que na data anterior à dos fatos, tinha recebido uma proposta de Alexandre, conhecido como Ney Caroço, para traficar no local; estava trabalhando em uma obra, como ajudante de pedreiro, e seu colega de trabalho adoeceu, razão pela qual não pôde trabalhar com ele; surgiu uma

oportunidade para traficar no local, conhecido por ser ponto do tráfico; na data dos fatos, tinha acabado de pegar as drogas para vender, e estava guardando os entorpecentes no latão de lixo, quando avistou os policiais e, disfarçadamente, dispensou os sete papелotes de pó atrás de um muro; na data dos fatos, ainda não tinha vendido as drogas; questionado qual a origem dos R\$ 200,00, disse que o dinheiro era de um colega seu, que estava traficando consigo; questionado por que estava com o dinheiro, já que era do seu colega, disse que ele tinha acabado de sair para almoçar e, como não tinha vendido nada, o dinheiro seria usado como troco; questionado quantas passagens tem na Vara da Infância, pelo mesmo tipo de delito, disse que três passagens; questionado se ficou internado três vezes e isso não serviu para aprender nada, disse que foi um erro seu; questionado sobre ser o quarto erro, fora os que não foi pego, disse que tinha acabado de retornar, e queria fazer um dinheiro, pois tinha acabado de sair de uma obra de pedreiro e não estava recebendo; como é maior de idade, não gosta de ficar esperando as coisas; tentou procurar trabalho uns dias antes, mas como Ney Carôço veio falar consigo, aceitou, pois já sabia como funcionava, mas se arrepende; estudou até o segundo ano do colegial; não estava desenvolvendo nenhuma atividade lícita remunerada; é usuário de maconha, então entrou para o tráfico para sustentar seu vício, sendo que é usuário desde os quinze anos de idade; questionado se nunca procurou ajuda para se tratar, disse que nunca teve essa oportunidade (fls. 200/201).

A testemunha Valdiney Rodrigues Pereira, guarda municipal, ouvida às fls. 200/201, disse que estava em moto-patrolhamento em um local amplamente conhecido pelo tráfico de drogas, no intuito de coibir a traficância, uma vez que no local há uma escola, uma biblioteca e uma quadra de esporte utilizada por crianças, momento em que visualizaram um indivíduo mexendo em um latão; o indivíduo, ao avistar a equipe, tentou sair rapidamente do local, vindo a dispensar, logo à frente, alguma coisa branca, atrás de um muro; em seguida, o indivíduo foi abordado, e seu colega foi para trás do muro, onde encontrou sete porções de cocaína, sendo que, no latão, foram localizadas mais algumas porções de cocaína, separadas individualmente e prontas para a venda, além de algumas "buchas" de maconha, envoltas em um saco preto, vulgarmente conhecido como "mula", e pedras de crack; em frente ao local onde o réu foi abordado, há uma quadra de esportes, utilizada por crianças no dia-a-dia, além de uma biblioteca e uma escola infantil, que ficam ao lado; as porções de cocaína que foram jogadas para trás do muro eram idênticas às que estavam no latão, juntamente com as outras drogas; diante disso, foi dada voz de prisão ao réu, em razão da convicção da equipe de que ele estava na traficância, ocasião em que compareceu um indivíduo que se intitula membro de uma facção criminosa, e que é conhecido nos meios policiais como Ney Carôço; o indivíduo tentou coagir a equipe, dizendo que não precisava levar o réu, no entanto, CAIO foi conduzido à Delegacia; o réu veio a confessar que estava realmente traficando, sendo que já é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, quando ainda era menor de idade.

A testemunha André Luís dos Santos Pinto, guarda municipal, ouvida às fls. 200/201, disse que estava em patrulhamento com motocicleta, juntamente com sua equipe, em região conhecida pela traficância quando, ao acessar a via pública, visualizou CAIO em frente ao um bar, mexendo em um tambor de duzentos litros, o qual continha lixo; o réu, ao notar a presença da equipe, tentou sair do local, dispensando um volume de cor branca, o qual jogou para trás de um muro; feita a abordagem, seu colega foi verificar o tambor de lixo, enquanto foi ver o que havia sido jogado para trás do muro, constatando que se tratavam de sete invólucros contendo uma substância branca, posteriormente identificada como cocaína; seu colega achou, no tambor de lixo, em um saco preto, outra quantidade da mesma droga, além de outros entorpecentes, quais sejam, maconha e crack, razão pela qual foi dada voz de prisão ao réu que, a princípio, negou o tráfico mas, como foi visto arremessando as drogas no muro, veio a admitir a traficância, na Delegacia; durante a abordagem, compareceu Alexandre, conhecido nos meios policiais pela alcunha de Ney Carôço, e questionou se a equipe conduziria o réu, a quem Alexandre se referiu como "meu menino", ao que respondeu que CAIO havia sido flagrado traficando; o local da prisão é uma praça, frequentada por crianças, sendo que há uma escola municipal e

uma biblioteca nas imediações; já conhecia o réu de outras abordagens, sendo que ele já tinha sido apreendido outras três vezes, quando era menor de idade; questionado se já tinha apreendido o réu antes, disse que não, mas sua equipe já deu apoio a outros colegas que apreenderam o réu, quando ele era menor.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em fase policial, negou os fatos, sendo que, em juízo, confessou o crime, narrando que estava procurando trabalho, quando recebeu uma proposta para traficar no local, feita por um indivíduo conhecido como Ney Caroço. Disse, ainda, que estava traficando porque "não gosta de ficar esperando as coisas" e para sustentar seu vício, alegando que é usuário de drogas desde os quinze anos.

A confissão veio corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais, que narraram, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando viram o réu mexendo em um latão, momento em que CAIO visualizou a equipe e tentou sair rapidamente do local, dispensando, logo à frente, um volume, atrás de um muro. Narraram, também, que o referido volume continha sete porções de cocaína, prontas para a venda, embaladas de maneira idêntica a outras porções da mesma droga, encontradas dentro do latão em que o réu estava mexendo, juntamente com algumas "buchas" de maconha e pedras de crack. A testemunha Valdiney relatou, ainda, que durante a abordagem, um indivíduo conhecido nos meios policiais como Ney Caroço, e que se intitula membro de uma facção criminosa, tentou coagir a equipe, tendo o guarda André narrado que Ney Caroço se referiu ao réu como "meu menino".

Conveniente rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, os depoimentos dos agentes da Lei ouvidos merecem total credibilidade e servem perfeitamente como supedâneo para prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na gratuita acusação do réu.

Ademais, é sabido que os guardas municipais integram os quadros funcionais do Município e possuem por função básica a defesa do patrimônio público municipal. Importante ressaltar, entretanto, que estes agentes públicos possuem uma atuação secundária: cabe aos guardas municipais a defesa da população local. Tal defesa pode se dar, inclusive, na forma de repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos.

E é importante destacar que os guardas municipais, caso assim não ajam, podem

responder na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, uma vez que possuem o dever de agir, posto que a lei lhes obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disto, a preservação da ordem pública é da responsabilidade de todos - tanto que a um popular é conferido o direito de dar voz de prisão em flagrante a outrem -, sendo que aos Órgãos de segurança, é conferido o dever legal de tal preservação. Assim, é conferida à Guarda Civil Municipal, a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie e averigue os fatos, incluindo-se, nisto, a revista pessoal.

Sobre o tema:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA. PRECEDENTES. (...) 2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, § 8º, CF), bem como qualquer um do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP). (...) (STJ HC 290.371/SP 5ª Turma Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.2014 DJe 30.05.2014).

Ainda neste sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei processual penal, em momento algum, exige que policiais civis ou militares sejam acionados para que dêem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a prisão, como aventado na impetração. Precedentes. (...) (STJ - RHC 45.173/SP 5ª Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. 06.05.2014 DJe 14.05.2014).

E ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, § 8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". (...) (STJ - HC 109.105/SP 5ª Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.2010 DJe 22.03.2010).

Não obstante, a Lei n. 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais, complementa o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Segundo tal dispositivo constitucional, as Guardas Municipais devem ser disciplinadas por meio de Lei, e a Lei n. 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as Leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar suas próprias normas a respeito, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Curial ressaltar que o Estatuto amplia a restrita interpretação do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, ao asseverar que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". As Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal, sendo que a Lei 13.022/14 amplia a interpretação, antes restritiva, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

O artigo 4º de referido Estatuto atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, de acordo com o que já se encontra previsto na Constituição Federal. O artigo 5º, por sua vez, indica competências específicas, dentre elas, o fato de que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social. Eis a letra da Lei:

"Art. 5º (...)

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.(...)"

Nem se diga existir qualquer inconstitucionalidade da Lei n. 13.022/14, por ter, referido normativo, conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em defesa da segurança pública. As Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado - razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal, contido, por sua vez, no Capítulo III, cujo título é "Da Segurança Pública".

Além disto, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atinente à colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar), como já analisado acima. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio considerado necessário.

Considerando que as Guardas Municipais são corresponsáveis pela garantia da paz social, devendo atuar inclusive na prevenção da prática de delitos, possuindo o dever de impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso, não há que se falar em irregularidade na atuação da Guarda Municipal nos fatos ora apurados.

Assim, somando-se a confissão com os depoimentos dos Guardas Municipais, verifica-se que o réu estava na traficância, sendo o robusto conjunto probatório trazido aos autos plenamente apto a comprovar que o réu efetivamente praticou o crime pelo qual foi denunciado, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 38/40). Sobre a culpabilidade, nada a considerar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas.

Quanto à natureza e quantidade do produto, verifica-se que o réu trazia consigo drogas das mais variadas, sendo 14 porções de maconha, 13 porções de cocaína e 9

pedras de crack, além de R\$ 200,00 em notas trocadas, dinheiro que o próprio réu admitiu que era oriundo do tráfico.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente reprimida (artigo 42, Lei 11.343/06). Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

A maconha, bem como a cocaína, são entorpecentes ilegalmente inseridos e disseminados na sociedade pela traficância, não raro consumidas até mesmo por crianças e adolescentes. Quanto à cocaína, trata-se de entorpecente ilegalmente inserido na sociedade, causador de verdadeiras tragédias pessoais, familiares e sociais, possuindo considerável poder viciante.

Assim, diante da quantidade e variedade, além do grau de nocividade e poder viciante das drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade, decretado em março de 2020, em razão da pandemia covid-19, bem como a atenuante da confissão, prestada pelo réu em juízo.

O pleito da defesa de afastamento da agravante do art. 61, II, j, sob a alegação de que não restou comprovado o melhor proveito à prática criminosa em razão do estado de calamidade, não pode ser acolhido. O Código Penal não prevê que o estado de calamidade facilite a prática delitiva, mas sim prevê que a pena se agrava quando o fato é praticado em referido estado, como é o caso dos autos.

Assim, compenso a agravante do estado de calamidade com a atenuante da confissão, neutralizando seus efeitos, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 09). No entanto, em observância à Súmula 231, do STJ, a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo, retornando, portanto, a 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de aumento de pena.

Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não obstante ser o réu tecnicamente primário, há de se considerar que o próprio réu admitiu o envolvimento com a narcotraficância, já tendo sido processado por tráfico de drogas anteriormente, antes de atingir a maioridade, portanto, segue nessa atividade ilícita há bastante tempo, não havendo dúvidas quanto ao seu envolvimento com o meio delitivo. Ademais, não se pode ignorar que, conforme relatado pelos guardas, durante a abordagem, um indivíduo conhecido nos meios policiais como Ney Caroço, que se intitula membro de uma facção criminosa, compareceu ao local e tentou coagir a equipe a não prender o réu, a quem Ney Caroço se referiu como "meu menino", sendo evidente o profundo envolvimento do réu com a traficância, não se aplicando, assim, o benefício do parágrafo quarto, por se dedicar às atividades criminosas.

Por fim, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas, não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a lei deu a faculdade de aplicar o benefício do

parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez.

Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor.

Conforme brilhante explanação de EDILSON MOUGENOT BONFIM, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor: "Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que ele componha uma 'sinfonia criminosa musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminosa', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que

mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, verifica-se que todo "pequeno traficante" faz parte de uma imensa rede, chamada crime organizado, sendo eles a ponta danosa do iceberg, por serem quem leva a droga aos usuários, expondo a vida e saúde deles. Por tal razão, não há que se falar em tráfico privilegiado.

Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende - eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente - geralmente identificado como o "pequeno traficante" - deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada

ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumprе ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será

detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno CAIO DOUGLAS SILVA DOMICIANO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e multa de 500 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

DECRETO a perda do dinheiro apreendido com o réu, dando-se a devida destinação. O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foi condenado, seja colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, nos termos acima fundamentados. A prática exige punição exemplar. Ademais, não há segurança ao juízo de que o réu, uma vez em liberdade, não acabe voltando a praticar o delito que culminou com sua prisão, seja para saldar eventual dívida que ostente com o tráfico, em razão da apreensão das drogas, seja para garantir seu próprio sustento, especialmente considerando que ele mesmo confirmou seu envolvimento com a narcotraficância desde que era menor de idade. Além disto, permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da

gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
P.R.I. e C.
Atibaia, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA